

1501819-88.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501819-88.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501819-88.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209424/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 26507989 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2209424 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DE FREITAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

BRENO RICARDO COSTA LUZ e CARLOS HENRIQUE DE FREITAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 14h30, na Rua Coronel Francisco Schmidt nº 345, Centro, nesta cidade e Comarca de Sertãozinho, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 07 (sete) pedras de "Crack" pesando cerca de 32,89g e 01 (um) pacote contendo Cocaína e pesando cerca de 1.048,47g, substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu a informação anônima de que, no endereço supracitado, estariam depositadas substâncias

entorpecentes, diante do que rumaram ao local. Ao chegarem lá, os policiais notaram a presença de dois indivíduos que se evadiram assim que perceberam a aproximação da viatura. Eles passaram a pular os telhados dos imóveis vizinhos e foram perseguidos, sendo que um deles, identificado como o réu Breno, acabou sendo detido pelos patrulheiros. Seu comparsa, identificado como o réu Carlos Henrique, foi localizado apenas alguns dias depois dos fatos. No terreno em que ambos se encontravam, foram encontradas, com o auxílio de um cão farejador, 7 (sete) "pedras" de "Crack" e 1 (um) pacote contendo "cocaína" em pó, drogas que estavam enterradas no solo. No mesmo local, foram apreendidos petrechos destinados à preparação e à embalagem de entorpecentes, a saber: 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) faca e 1 (um) pacote contendo cerca de 5000 (cinco mil) cápsulas do tipo eppendorf vazias. Breno admitiu informalmente aos policiais a propriedade dos estupefacientes e sua destinação ao comércio ilícito, dizendo também que estava mancomunado com Carlos.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2022 (fls. 132/137), os réus foram citados (Carlos Henrique - fls. 152; Breno - fls. 187) e apresentaram resposta à acusação (Carlos Henrique - fls. 173/175; Breno - fls. 159).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pelas partes, três testemunhas arroladas pela defesa, sendo os réus interrogados ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa do réu Breno requereu a absolvição, por não haver provas de que o acusado tenha concorrido para a infração penal e por falta de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da atenuante da menoridade e reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, com aplicação do regime inicial aberto ou intermediário e concessão do direito ao recurso em liberdade.

A Defesa do réu Carlos Henrique requereu a absolvição, com fundamento nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 do SISNAD em sua fração máxima, aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a concessão do direito do réu recorrer em liberdade, considerando a inexistência dos requisitos legais previstos no art. 312 de lei adjetiva penal.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06 e 14), pelos boletins de ocorrência (fls. 41/43 e 153), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelas imagens fotográficas (fls. 23/25 e 38/40), pelo auto de constatação preliminar (fls. 17/18), pelo laudo pericial (fls. 106/111), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 112/114), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os policiais militares Paulo Roberto e Edgar, na fase policial, disseram que receberam denúncia anônima sobre o depósito de substâncias entorpecentes no local do delito, até lá se dirigindo afim de averiguar o fato. Chegando ao local, observaram que dois indivíduos que ali estavam, ao perceberem a presença policial, rapidamente partiram em fuga, pulando ao telhado de imóveis vizinhos. Tais indivíduos foram imediatamente perseguidos pelos depoentes, porém apenas um deles acabou detido e identificado como o réu Breno. Revistado, nada foi encontrado em sua posse. O segundo indivíduo, em que pese as diligências policiais realizadas, conseguiu se evadir, porém foi identificado como o réu Carlos Henrique. Ainda, em revista ao local, tratando-se de um terreno, onde os acusados se encontravam, utilizando um cão farejador, encontraram, enterradas ao solo, as substâncias entorpecentes apreendidas, especificamente 07 (sete) pedras da droga "crack" (cerca de 32,89g) e 01 (um) pacote contendo cerca de 1.048,47g da substância entorpecente vulgarmente denominada "cocaína" em pó. Também no local do delito, apreenderam

petrechos destinados à preparação e embalagem das drogas para o posterior comércio ilegal, tais como 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca e um pacote contendo cerca de 5.000 (cinco mil) cápsulas do tipo "eppendorf" vazias. Inquirido sobre o fato, o acusado Breno admitiu a propriedade das drogas apreendidas, reconhecendo que se destinavam ao posterior comércio ilegal. Admitiu, também, a prática delitiva em unidade de desígnios com Carlos Henrique, que conseguiu se evadir. Até o presente momento, não havia notícias do paradeiro de Carlos Henrique, permanecendo, pois, foragido (fls. 10/11 e 12/13).

Em Juízo, a testemunha Paulo Roberto, policial militar, disse que na data dos fatos, em patrulhamento no Jardim Alvorada, receberam notícia anônima diretamente à equipe, relatando que os acusados estavam em atitude de tráfico de drogas, acusados já conhecidos pelo comércio de entorpecentes. Em razão da notícia de crime, solicitaram apoio de outros policiais, inclusive do canil e, ao tentarem a abordagem, os acusados empreenderam fuga, via telhado, sendo exitosa a abordagem de Breno, não sendo possível localizar o acusado Carlos Henrique. Após diligências no imóvel, com características de terreno baldio, para uso de reciclagem, utilizando-se dos cachorros do canil, foi possível localizar as drogas descritas no auto de apreensão, bem como utensílios para embalagem e pesagem de entorpecentes. Ato contínuo, o acusado Breno foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia. Aos questionamentos do Ministério Público respondeu que em patrulhamento próximo ao local dos fatos foram acionados por um popular, o qual não quis ser identificado, passando este a narrar a ocorrência do embalo de drogas, em um local próximo ao Jardim Alvorada. Disse que foi o popular que descreveu o local como um terreno baldio próximo a uma funilaria, bem específico, relatando, ainda, o nome dos acusados, já conhecidos dos meios policiais. Aduziu que por se tratar de uma cerca viva, foi possível visualizar os acusados, os quais acessaram o telhado e partiram em fuga. A apreensão das drogas foi feita por outra equipe, a equipe do canil, sendo o depoente responsável pela prisão de Breno. Asseverou que os acusados estavam no local da apreensão das drogas. Salientou que Breno confessou informalmente a traficância, declinando, outrossim, o nome do corréu Carlos Eduardo. Questionado pela defesa do acusado Breno, disse que no momento da abordagem o acusado Breno estava no interior do terreno, o qual fica ao lado da oficina. Esclareceu que a oficina fica na esquina da rua, de forma que a depender do local de onde se observa, referido terreno pode ser considerado fundos da oficina ou terreno vizinho, vindo pela Rua Franciso Schimdt, é considerado terreno vizinho, com clara visualização de seu interior em razão da existência de uma cerca viva. Esclareceu que não foi possível conversar com o proprietário da oficina, pois quando a viatura chegou ao local todos abandonaram o imóvel, sendo possível visualizar os réus sentados no dito imóvel, mas não foi possível visualizar nenhum deles manuseando drogas. Aos questionamentos da defesa de Carlos Eduardo, disse que no momento da abordagem a oficina instalada no local dos fatos estava aberta, não sendo localizado o proprietário. Aduziu que no terreno baldio possui cerca viva, além de arames farpados, sendo difícil seu acesso. Disse não se recordar a quantidade de pessoas existentes no local no momento da abordagem. Asseverou que após a abordagem somente localizaram o réu Breno, não tendo se deslocado até a casa de Carlos Henrique, pois as diligências ficaram circunscritas aos arredores do local dos fatos (v. mídia).

Em Juízo, a testemunha Edgar, policial militar, disse que na data dos fatos, em patrulhamento no Jardim Alvorada, receberam notícia anônima diretamente à equipe, relatando que os acusados estavam em atitude de tráfico de drogas, fracionando drogas para vendas. Em razão da notícia de crime, solicitaram apoio de outros policiais, inclusive do canil e, ao tentarem a abordagem, os acusados empreenderam fuga, via telhado, sendo exitosa a abordagem de Breno, não sendo possível localizar o acusado Carlos Henrique, o qual foi reconhecido pelos policiais militares, pois estava bem próximo. Após diligências no imóvel, com características de terreno baldio, para uso de reciclagem, com o uso dos cachorros do canil foi possível localizar as drogas descritas no auto de apreensão, bem como utensílios para embalagem e pesagem de entorpecentes. Aos questionamentos do Ministério Público, asseverou que teve contato visual com os dois réus. Disse, ainda, que no local de

apreensão estavam os acusados, os quais estavam fracionando "crack". Asseverou já conhecer os denunciados por abordagens policiais, mas não efetuou prisões, salientando que foram abordados em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. Relatou que foi ele o responsável por pedir apoio as demais equipes, sendo que a notícia anônima foi repassada ao seu colega de guarnição. Aos questionamentos da defesa de Breno disse que a notícia de crime foi feita pessoalmente. Asseverou que na oficina próxima ao local dos fatos estava o proprietário, esclarecendo que a apreensão de drogas ocorreu no terreno nos fundos da referida oficina. Consignou que não havia outras pessoas no terreno baldio. Asseverou que não viu os acusados manuseando as drogas, mas presenciou os réus abandonando o local após a chegada da guarnição policial. Disse que o "crack" que os acusados estavam manuseando não estava enterrado, estava sobre um pano e uma pedra utilizados para corte da droga, já os demais entorpecentes estavam enterrados, dissertando, ainda, que a distância entre os réus e as drogas enterradas era no máximo de um metro. Esclareceu que o terreno onde foram localizados os entorpecentes não era baldio, é cercado e possui portão. Asseverou que o terreno fica nos fundos da oficina e que pela posição que a viatura chegou não era possível visualizar nada de dentro do referido imóvel, sendo necessária a incursão no imóvel para verificar seu interior. Disse que após incursão no terreno foi possível visualizar os increpados. Aduziu que foi possível visualizar os acusados e foi feita a abordagem apenas de Breno. Questionado pela defesa de Carlos, disse que o proprietário da oficina não acompanhou a incursão no terreno vizinho, pois não fazia parte do estabelecimento. Asseverou que havia um portão no terreno onde as drogas foram apreendidas, o qual estava aberto. Disse que após os fatos não foram até a casa do acusado Carlos visando sua prisão, pois o acusado Breno já o tinha indicado como a pessoa que o acompanhava (v. mídia). A testemunha Fábio, arrolada pela Defesa de Carlos, disse ser amigo do acusado Carlos, conhecendo-o há dois anos do bairro Jardim Alvorada, sendo que o acusado trabalha como servente de pedreiro, aduzindo serem companheiros de pescaria de forma esporádica. Aos questionamentos da defesa de Carlos, dissertou que próximo ao dia dos fatos, o depoente foi chamado para pescar com o acusado, no pesqueiro de Dumont, aduzindo que na ocasião o réu Carlos recebeu uma ligação de sua irmã, a qual disse que a polícia o procurava. Disse que ficaram no pesqueiro até às 18 horas. Questionado pelo Ministério Público, disse no pesqueiro de Dumont estava acompanhado do acusado Carlos e de sua namorada. Asseverou trabalhar como motorista canavieiro. Sobre a data exata em que estavam no pesqueiro, não soube declinar, também não sabendo ao certo o nome da namorada ou sua idade. Disse que quando estava com o réu era seu dia de folga, sendo que sua jornada de trabalho consiste em trabalhar quinze dias com um dia de folga, podendo a folga ocorrer em qualquer dia da semana (v. mídia).

A testemunha Michelle, arrolada pela Defesa de Carlos, disse ser irmã de Carlos. Asseverou que mora três ruas a frente da residência do acusado Carlos, possui contato com o irmão em razão de sua mãe. Questionada pela defesa de Carlos, disse que quando tomou conhecimento dos fatos, sobre a prisão do acusado Breno, o qual estaria com seu irmão, partiu rumo à residência deste último. Asseverou que após saber que seu irmão não estava no local, ligou para ele, o qual dissera que estaria em um pesqueiro, avisando-o sobre a busca da polícia por ele, em razão dos fatos em apuração. Aduziu que pediu para o irmão não ir, visando evitar sua associação ao delito. Relatou que seu irmão Carlos estava no pesqueiro na companhia da testemunha Fábio. Disse que Carlos não foi procurado pela polícia na casa de sua mãe.

Dissertou que o acusado Carlos já foi abordado algumas vezes pela polícia. Questionada pelo Ministério Público, disse que Breno e Carlos são amigos há muito tempo, porém, após Breno ter se casado se afastaram, afirmando já conhecer Breno em razão desta amizade. Disse que Carlos trabalhava como servente de pedreiro, com certa frequência, porém não todos os dias. Sobre os fatos tem lembranças de que ocorreram em dia de semana. No que se refere a testemunha Fábio, afirmou o conhecer em razão de ser companheiro de pescaria de Carlos, mas este não morava perto de sua residência (v. mídia).

O réu Breno, quando interrogado na fase policial, negou a prática delitiva, alegando que no dia dos fatos foi até a oficina para consertar o seu veículo. Lá

estava aguardando, quando adentrou à oficina vários Policiais Militares. Alega que em nenhum momento tentou fugir do local. Atrás da oficina, apenas visualizou que havia alguns indivíduos naquele local, não reconhecendo nenhum. Alega não serem de sua propriedade os entorpecentes apreendidos (fls. 09). Em Juízo, o acusado Breno negou o cometimento do delito, asseverando que estava no local dos fatos, na oficina, mas não com as drogas. Salientou que deixou seu veículo dois dias atrás na oficina para consertar, indo busca-lo para trazer sua esposa de volta para casa após ter recebido alta, pois acabara de dar a luz sua filha. No dia dos fatos estava em frente da oficina esperando o proprietário, na esquina, quando chegou uma viatura policial, ocasião onde foi revistado, após, chegaram outras viaturas, sendo localizadas as drogas, as quais não eram de sua propriedade. Negou estar com as drogas e na companhia de Carlos, negando, ainda, que tenha pulado muros, sendo que ficou parado na abordagem, respondendo as perguntas. Disse que ninguém saiu correndo no momento da abordagem policial, nada viu sobre isso. Asseverou não ter visto o local onde as drogas foram localizadas. Dissertou já conhecer os policiais de outras abordagens, salientando que já foi ameaçado pelo policial Paulo para retirar a reclamação, o que foi feito por medo. Disse que conhecia Carlos há certo tempo, mas dele se afastou após ter se casado. Asseverou que na época dos fatos não estava exercendo atividade remunerada. Dissertou que quando era adolescente já se envolveu com drogas. Disse que já foi preso e processado anteriormente por drogas. Questionado pela defesa de Carlos, asseverou que o acusado Carlos não estava em sua companhia, ressaltando que a abordagem foi feita fora da oficina. Aduziu que teve conhecimento de que Carlos era réu no processo quando recebeu a citação. Aos questionamentos da defesa de Breno, disse residir no Bairro Santa Rosa II. Asseverou que recebia pensão mensal de sua mãe. Dissertou que reside com sua avó e prima (v. mídia).

O réu Carlos Henrique, quando interrogado na fase policial, negou a prática delitativa, alegando que conhece Breno de longa data, mas não tem tanta convivência com ele há algum tempo. Ficou sabendo da prisão do corréu pela Polícia Militar e, no dia dos fatos, o interrogando estava pescando no pesque pague de Dumont. Ficou sabendo da prisão por uma ligação de sua irmã, a qual informou que a polícia militar estava dizendo, quando da prisão de Breno, que teriam visto o interrogando fugindo do local. Alega que até pensou em se apresentar para dizer que estava no pesque pague e que a pessoa que fugiu do local não era o interrogando, mas sua irmã lhe orientou a não fazer isso, pois poderia acabar sendo preso junto com Breno. Nega que estivesse no mesmo local ou em associação a Breno, quando ele foi preso por tráfico de drogas na semana passada. Reitera a alegação de que estava no pesque pague de Dumont no momento da prisão. Alega não ter qualquer relação com as drogas apreendidas naquela ocorrência (fls. 94). Ouvido em Juízo, o acusado Carlos negou os fatos, aduzindo que não estava com o acusado Breno no dia dos fatos, no momento da abordagem policial, alegando que estava em um pesque pague, na cidade Dumont, na companhia de Paulo, Fábio e esposa deste. Asseverou que os policiais que atenderam a ocorrência podem ter passado próximo à sua residência e feito sua abordagem, contudo, nada tem contra eles. Dissertou conhecer Breno de longa data. Sobre a apreensão de drogas, ficou sabendo de sua irmã, em razão da prisão de Breno, relacionando seu nome ao delito, aduzindo que pensou em comparecer à Delegacia, porém, foi convencido por sua irmã a não fazê-lo. Questionado pela defesa de Carlos, disse que antes da prisão morava com sua mãe e esposa, no bairro Jardim Alvorada (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que os acusados eram realmente os proprietários da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre o depósito de substâncias entorpecentes no local dos fatos, ao chegarem no local, avistaram os réus, que rapidamente partiram em fuga, pulando ao telhado de imóveis vizinhos, contudo, conseguiram deter o réu

Breno, o qual nada de ilícito tinha em sua posse.

O policial militar Paulo descreveu que o imóvel onde os acusados foram avistados possui características de terreno abandonado, fazendo fundo ou vizinhança com uma oficina de funilaria, de acordo com a rua de onde se observa. Ao se aproximar do imóvel declinado por um popular, prosseguiu o depoente, narrando que foi possível verificar a presença dos acusados. Já o policial militar Edgar foi preciso ao dizer que foi possível observar os denunciados manuseando drogas no local, inclusive utilizando-se de uma pedra como mesa e um lençol. Pelo policial militar Paulo foi relatado que haviam outras pessoas no local, as quais se evadiram, já os acusados foram flagrados pulando muros vizinhos quando da abordagem. De acordo com o policial militar Edgar não foram vistas outras pessoas no local, porém, o proprietário da funilaria estava presente, sendo que a incursão no terreno vizinho não contou com a presente deste último, já que não foi feita em seu imóvel. Em revistas ao local, tratando-se de um terreno, com auxílio de cão farejador, encontraram, enterradas ao solo, as substâncias entorpecentes apreendidas, especificamente 07 (sete) pedras da droga "crack" (cerca de 32,89g) e 01 (um) pacote contendo cerca de 1.048,47g de cocaína, além de petrechos destinados à preparação e embalagem das drogas para o posterior comércio ilegal, tais como 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca e um pacote contendo cerca de 5.000 (cinco mil) cápsulas do tipo "eppendorf" vazias.

Embora os relatos dos agentes de segurança destoem em detalhes, é certo que ambos avistaram os increpados no local onde as drogas foram localizadas, os quais partiram em fuga quando avistados, sendo certo, ainda, que as drogas enterradas foram encontradas no mesmo imóvel com ajuda do canil da polícia militar, não havendo justificativas para a presença dos réus no local.

Os acusados, por sua vez, negaram a prática delitiva.

O réu Breno alegou que estava em uma oficina próxima ao local dos fatos para consertar o seu veículo e que visualizou alguns indivíduos no terreno local dos fatos. Negou, portanto, a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

O réu Carlos Henrique alegou que estava em um pesque e pague no momento dos fatos, não possuindo qualquer relação com as drogas apreendidas.

Entrementes, as versões dadas pelos acusados não foram corroboradas pelas fontes de provas desenvolvidas, restando isoladas nos autos e incapazes de infirmar a convicção judicial posta na exordial acusatória.

O acusado Breno asseverou que estava na oficina de funilaria para retirar seu carro que lá havia deixado há alguns dias, já que se preparava para buscar sua esposa que acabara de dar a luz à sua filha. Não obstante o acusado Breno tenha juntado prova da gravidez de sua companheira e de sua internação no dia 01/08/2022, um dia antes dos fatos, folhas 46/49, deixou de trazer aos autos elementos de provas de que estava no local dos fatos para retirar seu veículo destinado a atender sua família em momento tão importante, deixando de arrolar o dono da oficina de funilaria como testemunha ou alguma forma de escrito que indicasse ter deixado o automóvel no local para reparos, como, por exemplo, um orçamento dos serviços a serem prestados. Nesta senda, suas alegações não provadas são incapazes de contrariar o quanto posto ao longo da instrução, ônus que lhe cabia, prevalecendo a descrição fática feita na denúncia, confirmada pelo arcabouço probatório.

No que tange ao acusado Carlos, este busca não ser responsabilizado pela conduta típica descrita na denúncia em razão de não estar no local dos fatos quando da abordagem policial, tendo como prova de seu álibi o testemunho de seu amigo Fábio e de sua irmã Michelle. Contudo, os policiais militares foram assertivos ao dizer que visualizaram o réu Carlos na companhia do corréu Breno durante a abordagem descrita no auto de prisão em flagrante relativo aos autos, tendo ambos tomado atitude de fuga através de muros vizinhos, cujo êxito da prisão em flagrante se deu apenas em relação a Breno, o qual, informalmente admitiu estar na companhia de Carlos. De acordo como increpado Carlos, no dia dos fatos ele estaria em um pesqueiro, localizado na cidade Dumont, na companhia de Fábio, sua esposa e uma terceira pessoa. Em seu depoimento, Fábio diz ser amigo do acusado Carlos e que são companheiros de pescaria, aduzindo que no dia dos fatos estariam juntos. Contudo, referida testemunha de defesa apresentou falas de pouca credibilidade. Fábio, ao

ser questionado, disse que estava em um pesqueiro na cidade de Dumont, na companhia de sua namorada e do acusado Carlos, contudo, não soube declinar o nome da suposta namorada ou sua idade, além de não saber sequer o dia da semana em que esteve no local de entretenimento pescando com o acusado. Em seu interrogatório, Carlos menciona que Fábio estava acompanhado de sua esposa, sendo que este último diz ser sua namorada a pessoa que o acompanhava, restando certo que seja esposa ou namorada não é crível que sequer saiba o nome da pessoa com quem convivia ou conviva mediante relação de afeto.

Para além disso, segundo o réu Carlos e a testemunha Fábio, outras pessoas estavam no pesqueiro no dia dos fatos, entretanto, nenhuma delas foi arrolada como testemunha de defesa. Por outro lado, tratando-se de local frequentado por várias pessoas, sob a direção de um proprietário, com vendas de produtos e prestação de serviços, seria possível trazer aos autos notas de consumo ou conjêneres indiciários da presença do acusado e seu companheiro de pescaria no estabelecimento mencionado.

Nesta senda, presente relação antiga de amizade entre os acusados, conforme admitido por eles, e confirmada a presença de ambos no local dos fatos pelos policiais militares, ausentes elementos de provas que coloquem quaisquer dos réus fora do cenário criminoso, o álibi levantado pelo acusado Carlos não restou devidamente configurado, devendo prevalecer a imputação feita na denúncia. No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares – Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 – Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib – d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa os réus, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão dos acusados - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando que a significativa quantidade de droga encontrada é superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, sendo elas a cocaína e o "crack", bem como o fato de terem sido encontrados também no local apetrechos comumente utilizados para o preparo de porções de entorpecentes, no caso duas balanças de precisão, uma faca contendo resquícios de droga, conforme comprova laudo pericial de fls. 106/111, e um pacote contendo cerca de 5.000 cápsulas do tipo "eppendorf" vazias, e que ainda não foi comprovado de forma satisfatória o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, conclui-se que os réus realmente praticavam o tráfico na ocasião.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação dos réus como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu Breno era menor de 21 anos na data dos fatos, porém tal circunstância atenuante não tem o condão de fazer com que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Porém, no presente caso, observo que o réu Breno já respondeu pela prática uma grande quantidade de atos infracionais, inclusive equiparados ao tráfico de Drogas (v. certidão de fls. 210/211), tendo ficado internado por significativo período na Fundação Casa.

O réu Carlos também já foi condenado de forma definitiva pelo delito de associação ao tráfico de drogas (autos nº 1500994-11.2020 - fls. 212), condenação esta que não gera reincidência pelo fato de o trânsito ter ocorrido após os fatos tratados nestes autos.

Não bastasse, os réus ainda foram flagrados armazenando significativa quantidade de droga, como já mencionado. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva das drogas encontradas (crack e cocaína).

Considerando ainda a forma como foram detidos e a grande quantidade de droga que armazenavam, conclui-se que claramente se incorporaram à organização criminosa, ou, no mínimo, que têm se dedicado frequentemente à traficância, além de que não comprovaram nos autos, com segurança, o exercício de atividade remunerada lícita.

Por todos referidos motivos, os réus não pode ser considerados mero traficantes eventuais ou se sustentar que não se dedicam a atividades criminosas.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-

ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a

conduta social do agente.

A propósito, ressalto que os acusados guardavam significativa quantidade de droga, da forma como narrado na denúncia. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva das drogas encontradas (cocaína e "crack"). Breno também já respondeu pela prática de inúmeros atos infracionais equiparados ao tráfico perante a Vara da Infância e Juventude e Carlos também já foi condenado de forma definitiva por associação ao tráfico. Não há comprovação idônea de atividade remunerada lícita por parte dos réus. Por tais motivos, o regime fechado justifica-se como o mais adequado.

E também pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, ainda mais porque permaneceram presos durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus BRENO RICARDO COSTA LUZ e CARLOS HENRIQUE DE FREITAS, qualificados nos autos, cada qual à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Em face da condenação, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 26 de dezembro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA